

1502395-18.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502395-18.2021.8.26.0530

Controle: 2021/002289

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288981/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTOFER DANIEL DE JESUS AZEVEDO

Réu Preso

Aos 21 dias do mês de março de 2022, às 13:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS: o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; o réu Christofer Daniel de Jesus Azevedo, sua Defensora nomeada, Dra. RENATA FURTADO (OAB/SP 380126) e a testemunha arrolada em comum Policial Militar Paulo Roberto Caetano Júnior; COMPARECEU presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: a testemunha arrolada em comum Policial Militar Edgard Rogério Arantes. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas em comum Policiais Militares Paulo Roberto Caetano Júnior e Edgard Rogério Arantes, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Christofer Daniel de Jesus

Azevedo, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos.

CRISTOFER DANIEL DE JESUS AZEVEDO, vulgo "Pescoço", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 09h10, na Rua Guerino Bassetti nº 70, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 693 (seiscentos e noventa e três) porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos do tipo filme, e 01 porção grande e ainda não dividida também de maconha, acondicionada em um saco plástico, com peso total de 2.878,57g (dois quilos, oitocentos e setenta e oito gramas e cinquenta e sete decigramas), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o acusado praticava o tráfico de drogas nesta cidade de Sertãozinho. No exercício da atividade ilícita, Christofer trazia consigo 06 (seis) porções de maconha, guardava em um sofá 17 (dezessete) porções também de maconha e tinha em depósito 670 (seiscentos e setenta) porções de maconha e uma porção grande e ainda não fracionada da mesma droga. Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, "Praça do Pedregal", momento em que avistaram o acusado e resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram em poder do réu 06 (seis) porções de "maconha" e a quantia de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais). Em continuidade da abordagem referida, os agentes estatais encontraram em um sofá, próximo ao local onde o acusado estava, um conjunto com 17 (dezessete) porções de maconha, com formato e embalagens conhecida como "bananinha". Indagado a respeito, o acusado informalmente assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que o embalou durante a noite, no apartamento 32, bloco 34, do residencial Aragão 1, desta cidade. Diante da fundada suspeita do uso do imóvel para armazenamento de drogas e, portanto, da situação de flagrante, os agentes estatais rumaram até o imóvel indicado pelo acusado e, em buscas pelo local, localizaram petrechos para fabricação de drogas e outras 670 (seiscentas e setenta) porções de maconha, já embaladas e prontas para o comércio, além de uma porção grande também de maconha ainda não fracionada. Novamente indago, Christofer afirmou que o entorpecente seria de um indivíduo de alcunha "Pescoço", alcunha esta que seria do próprio acusado, conforme informações recebidas pelos policiais militares quando da lavratura do auto de prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 99/100), o réu foi citado (fls. 114) apresentou resposta à acusação (fls. 121/123).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, alegando, em síntese, não haver provas seguras acerca da propriedade da droga. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de penas mínimas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, do tráfico privilegiado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelas imagens fotográficas (fls. 14/19), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20), pelo laudo pericial (fls. 89/92), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 78/80 e 81/83), conclusivos

por se tratar de maconha, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução. A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. Os policiais militares Paulo Roberto e Edgar, na fase policial, disseram que na data dos fatos, em patrulhamento pelas imediações da "Praça do Pedregal", local bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado Christofer e resolveram abordá-lo. O réu tentou fugir da abordagem mas foi prontamente contido. Em seu poder, foram encontradas seis porções de erva aparentando "maconha" e R\$ 46,00. A cerca de dois metros de local onde estava o réu havia um sofá, sob o qual foi encontrado um "kit" com outras 17 porções idênticas às primeiras (formato conhecido como "bananinha", ou seja, embalagem fina e comprida). Indagado, o réu confessou estar traficando as drogas e, sobre a origem das drogas, alegou que havia passado a noite embalando-as no apartamento 32, do bloco 34 do Residencial Aragão 1, que seria de pessoa chamada "Pescoço". Em diligência no referido local, no qual não havia ninguém e não tinha móveis, foram encontradas as demais porções de drogas, tanto já embaladas de forma idêntica aquelas encontradas com o réu, como também a granel, além de petrechos destinados ao preparo da droga em porções como balança de precisão e plástico filme. O acusado alegou que tais coisas pertenceriam a um terceiro, do qual só sabia o vulgo, "Pescoço", porém, já durante a apresentação da ocorrência, apuraram que seria o próprio réu quem é que teria tal alcunha de "Pescoço" (fls. 05, 06 e mídia).

O réu, quando interrogado na fase policial, disse que no dia dos fatos saiu de casa, deixou sua namorada na casa dela e estava passando pela Praça do Pedregal quando parou para conversar com alguns "moleques", de nomes Fábio e Cleiton, de quem não sabe maiores dados. A viatura da PM passou por ali e não parou, ocasião em que tais rapazes saíram correndo. O interrogando, como não tinha nada de ilícito consigo, permaneceu parado. Enquanto uma viatura da PM foi ao encalço daqueles rapazes, outra veio até si e o abordou. Consigo foi encontrada apenas a quantia de R\$60,00, ou seja, nega que estivesse na posse de qualquer porção de droga. Os PM's revistaram um sofá ali próximo e encontraram debaixo dele um "pacote" com "maconha", indagaram-no sobre tais drogas, ao que disse nada saber. Assim, nega que tenha confessado aos PM's que estaria no local vendendo drogas. Nega que tenha apelido de "Pescoço". Na sequência, os PM's o levaram até uma casa abandonada para ver se havia guardado algo lá dentro. Revistaram o imóvel e nada localizaram. Pediram para desbloquear seu celular, o que foi feito. Viram uma foto do interrogando com seu colega "Fábio" fumando "maconha" no apartamento onde foram encontradas as outras drogas e "puxaram" a localização de tal imóvel, que fica no Residencial Aragão 1. Nega que tenha apontado aos PM's qual seria o apartamento onde havia tirado a tal foto. Eles foram em vários apartamentos até que encontraram o do bloco 34, apartamento 32, de onde saíram com diversas porções de "maconha", cuja propriedade o interrogando nega. No dia em que esteve no apartamento com Fábio, só viu um pote com "farelos" de "maconha" (pequena quantidade não prensada) no local, do qual tiraram parte para poder fumar. Assim, não sabia da existência das demais porções de drogas, balanças e demais objetos apreendidos no local. Já foi internado na fundação CASA duas vezes, por tráfico de drogas. Atualmente faz "bicos" de ajudante de pedreiro. Trabalhou na Coopercana por dois meses, através do "Sindicato de Movimentadores de Carga". Não sabe dizer se Fábio tem algum apelido. Às perguntas de seu advogado, respondeu que na oficina "Stock Motos", em frente onde estava quando foi abordado, há câmeras de segurança. Desde já o defensor solicita que sejam requisitadas as imagens de referidas câmeras no horário dos fatos (fls. 07).

Em Juízo, negou a acusação. Alega que foi abordado na rua Vitório Polegato, depois de sair da casa de sua namorada. Estava conversando com alguns moleques, que correram quando os policiais se aproximaram, tendo eles deixado cair um celular na fuga. Alega que mentiu em relação aos nomes dos menores que correram. Não correu, mas apenas saiu andando. Estava na posse do dinheiro apreendido mas não da droga. Foram caminhando até a praça do pedregal, onde passaram a efetuar buscas e encontraram droga. Os policiais foram até a residência do réu, onde nada de ilícito foi encontrado. Após, os policiais começaram a fazer buscas no Residencial Aragão, porque o celular apreendido, e que era de um dos moleques que fugiu, teria foto de

droga com localização deste local, e foram “de porta em porta”, até que realmente encontraram droga em um dos apartamentos, que estava mobiliado, não sabendo de quem seria. O apartamento estava fechado e a porta foi quebrada pelos policiais. Também foi agredido pelos policiais mas não ficou com marcas. Chegou a dar nome falso aos policiais, por medo, negando ter falado que teria o apelido de pescoço. Já ficou internado na Fundação Casa, por cerca de 1 ano, acusado de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, abordaram o acusado, encontrando em seu poder seis porções de maconha e R\$46,00 em dinheiro. Próximo do local onde o réu estava, cerca de dois metros de distância, dentro de um sofá, foram encontradas 17 porções idênticas às primeiras, em formato de “bananinha”. Ainda, em diligências no imóvel indicado pelo réu, onde teria passado a noite embalando a droga, foram encontrados petrechos como balança de precisão, plástico filme, e o restante da droga.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitativa, alegando inicialmente que não foi abordado em posse de drogas, bem como que no imóvel apenas fumou uma pequena quantidade de maconha com seu amigo Fábio, desconhecendo a existência das demais drogas no local. Porém, em Juízo, embora tenha reiterado a negativa, apresentou versão diversa, alegando que inclusive que o flagrante foi forjado, posto que, em realidade, não teria droga em sua posse e que a abordagem ocorreu cerca de 1 quarteirão de distância da praça onde os policiais encontraram mais droga. Porém, qualquer de suas alegações ficaram isoladas e não se sustentam, frente ao firme relato dos policiais. Também não encontrada respaldo em qualquer prova dos autos a alegação de que os policiais chegaram a bater, de porta em porta, até invadirem apartamento do Residencial Aragão onde havia o restante da droga.

No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-

74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Por fim, destaque que o montante de droga apreendido é superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários e grande parte da droga já estava embalada em porções próprias para comercialização (670 porções).

Também é certo que o réu não comprovou de forma satisfatória o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, indicando que realmente vivia desta prática ilícita.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a

condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. Porém, no presente caso, foi apreendida significativa quantidade de droga, a saber 693 (seiscentos e noventa e três) porções de maconha pesando 2.878,57 gramas, que além de indicativa de profissionalização na conduta, representa um perigo maior à saúde pública, por atingir inúmeros usuários, de forma que sua conduta evidentemente implica alto risco à sociedade.

A quantidade encontrada também indica que o réu possui forte e duradoura ligação com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria, fatores pelos quais se conclui não se tratar de traficância ocasional. E além do entorpecente, no local indicado pelo réu foi encontrada balança de precisão e plástico filme, petrechos comumente utilizados no preparo de entorpecentes, indicando claramente que se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo tem se dedicado frequentemente à traficância, notadamente porque não comprovado nos autos, com segurança, o exercício de qualquer atividade remunerada lícita por parte do réu.

Ademais, destaco que o réu já foi internado por cerca de 1 ano na Fundação Casa pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico, segundo ele próprio admitiu quando interrogado em Juízo e está comprovado a fls. 111/112.

Por todos referidos motivos, o réu não pode ser considerado mero traficante eventual ou se sustentar que não se dedica a atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça

material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 1º, “a” c.c. artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que o réu guardava relevante quantidade de droga, além de petrechos destinados ao embalo de droga, como balança de precisão e plástico filme. Não bastasse, o réu já foi internado por cerca de 1 ano na Fundação Casa pela prática de inúmeros atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e não comprovou, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, presumindo que vivia da prática do tráfico, a merecer ser duramente apenado.

E também pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego à réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CRISTOFER DANIEL DE JESUS AZEVEDO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e sua Dra. Defensora foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada Dra. Renata Furtado (OAB/SP 380126) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.